

予備独自問題 R2-25

(配点: 3)

月 日

月 日

伝聞証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、証拠とすることができる要件に差異のない書面の組合せが記載されたものの個数は、後記1から6までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 司法警察員の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるもの
- イ. 司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるもの
- ウ. 被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるものと、被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のいずれもないもの
- エ. 司法警察員が作成した検証調書と、司法警察員が作成した実況見分調書
- オ. 司法警察員から鑑定の嘱託を受けた者が作成した鑑定書と、裁判所から鑑定を命じられた鑑定人が作成した鑑定書

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No284	伝聞証拠	正答率
予備R2-25	正解 5	26%

ア 差異はない

司法警察員の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」(322条1項)であるから、その供述が、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」(任意にされたものでない疑があると認めるときを除く)又は「特に信用すべき状況の下にされたもの」であるときに限り、証拠能力が認められる。また、検察官の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものも、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」(322条1項)であるから、その供述が、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」(任意にされたものでない疑があると認めるときを除く)又は「特に信用すべき状況の下にされたもの」であるときに限り、証拠能力が認められる。したがって、両書面とも、証拠とすることができる要件に差異はない。

イ 差異がある

司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人以外の者………の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321条1項柱書)で、「前2号に掲げる書面以外の書面」(321条1項3号、3号書面)であるから、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき」で、「その供述が特に信用すべき状況の下にされたものであるとき」に証拠能力が認められる。これに対して、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人以外の者………の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321条1項柱書)で、「検察官の面前における供述を録取した書面」(321条1項2号、2号書面)であるから、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」又は「公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき」で「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の状況の存するとき」に証拠能力が認められる。したがって、両書面は、証拠とすることができる要件に差異がある。

ウ 差異はない

被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるものと、被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のいずれもないものは、いずれも、「被告人が作成した供述書」(322条1項)であるから、その供述が、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」(任意にされたものでない疑があると認めるときを除く)又は「特に信用すべき状況の下にされたもの」であるときに限り、証拠能力が認められる。アの記述で問題となった「被告人の供述を録取した書面」のように、「被告人の署名若しくは押印のあるもの」であることは要件とされていない。したがって、両書面とも、証拠とすることができる要件に差異はない。

エ 差異はない

司法警察員が作成した検証調書は、「司法警察職員の検証の結果を記載した書面」(321条3項)であるから、「供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したとき」に証拠能力が認められる。そして、司法警察員が作成した実況見分調書について、判例(最判昭35.9.8、百選A38事件)は、「刑訴321条3項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含するものと解するを相当とし、かく

解したからといって同条項の規定が憲法 37 条 2 項前段に違反するものでない」として、321 条 3 項の適用により、証拠能力を認める。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、検証も実況見分も捜査機関による実施態様や調書作成の業務的性格には差異はなく、強制捜査か否か、令状があるか否かにより証拠能力が認められる要件に差をつけることに合理的理由はない、ということを挙げる。したがって、司法警察員が作成した検証調書、司法警察員が作成した実況見分調書の両書面とも、証拠とすることができる要件に差異はない。

オ 差異はない

裁判所から鑑定を命じられた鑑定人が作成した鑑定書（鑑定人の鑑定書）は、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」（321 条 4 項）であるから、321 条 3 項と同一の要件である「供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したとき」に証拠能力が認められる。そして、判例（最判昭 28.10.15、百選 A39 事件）は、司法警察員から鑑定の嘱託を受けた者が作成した鑑定書（鑑定受託者が作成した鑑定書）について、「捜査機関の嘱託に基く鑑定書（223 条）には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する刑訴 321 条 4 項を準用すべきものである」として、321 条 4 項の準用により証拠能力を認めている。したがって、司法警察員から鑑定の嘱託を受けた者が作成した鑑定書、裁判所から鑑定を命じられた鑑定人が作成した鑑定書の両書面とも、証拠とすることができる要件に差異はない。

以上により、証拠とすることができる要件に差異のない書面の組合せが記載されたものは、ア、ウ、エ、オの 4 個であり、正解は肢 5 となる。

